

0000953-90.2017.8.26.0511

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO

Comarca: Rio das Pedras

Foro: Foro de Rio das Pedras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... a droga apreendida era destinada ao tráfico. Ao Estado-acusador incumbe demonstrar a configuração do tráfico, que não ocorre pelo simples fato da compra e da posse de entorpecente. Em suma, se a pessoa é encontrada com drogas, cabe ao Ministério Público comprovar que o entorpecente era destinado ao tráfico. Não fazendo esta prova, prevalece a versão defensiva. Este ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio das Pedras

Foro de Rio das Pedras

Vara Única

Rua Prudente de Moraes, 136, Centro., Centro - CEP 13390-003, Fone: (19) 2174-1604,

Rio Das Pedras-SP - E-mail: riодaspedras@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA - ASSENTADA

Processo Digital nº:

0000953-90.2017.8.26.0511 - Ordem nº 2017/001446

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 195/2017 - Delegacia de Polícia de

Rio das Pedras, 1087/2017 - Delegacia de Polícia de Rio das Pedras

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Luiz Henrique Dias Teixeira e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da audiência

01/06/2022 às 15:20h

Em 01 de junho de 2022, às 15 horas e 20 minutos, nesta cidade de Rio das Pedras, Comarca de Rio das Pedras, no Foro de Rio das Pedras, na sala de audiências da Vara Única, presente o Excelentíssimo Sr. Dr. DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO, MM Juiz de Direito, comigo escrevente. Também COMPARECERAM: O representante do Ministério Público, Dra. Erika Angeli Spinetti; o Réu: Luiz Henrique Dias Teixeira; o Defensor Dr. Guilherme dos Santos Kohari; e as testemunhas: Rafael Rodrigues Oliveira e Gustavo Cesar de Cinque Soares. Em seguida, com as formalidades legais, o MM Juiz de Direito passou a ouvir as testemunhas e interrogar o réu, tudo gravado por meio de sistema audiovisual, conforme mídias anexadas aos autos. Após, pelas partes foi dito que não tinham mais provas a produzir. Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça para alegações finais orais, assim se manifestou: "Meritíssimo Juiz, LUIS HENRIQUE DIAS TEIXEIRA foi denunciado e está sendo processado como incurso n artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, tendo em vista os fatos narrados na denúncia. Após regular instrução processual, a presente ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade delitativa foi comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos autos de exibição e apreensão de fls. 08 e 09, pelo auto de reconhecimento de objeto de fls. 43, pelos laudos de exame pericial de fls. 58/60 e 61/63, pelo laudo bem como pela

prova oral colhida ao longo da instrução processual. A autoria é certa e segura. Os policiais militares Rafael Rodrigues de Oliveira e Gustavo César de Cinque Soares relataram que estavam em regular serviço quando receberam a informação de que havia um indivíduo armado no "Bar da Madalena"; que se deslocaram ao local indicado e lá abordaram os acusados; que com Vando foi encontrado um simulacro de arma de fogo, do tipo pistola, na cor preta e com Luís Henrique foram localizadas 28 porções de Crack e 08 porções de maconha; que Luís afirmou que a droga era destinada à venda e Vando alegou que o simulacro era utilizado para espantar gatos da vizinhança; que sobre o referido local pendiam recorrentes notícias acerca de tráfico ilícito de entorpecentes. O acusado Luís Henrique, em sede inquisitiva, admitiu a propriedade do entorpecente, mas alegou que se destinavam a consumo próprio. Acrescentou que já foi preso pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Em juízo, negou a prática do crime e afirmou que consigo nada foi apreendido. Conforme se verifica dos autos, tais versões não merecem crédito, eis que não encontram respaldo em nenhum elemento de prova colhido ao longo da instrução processual. A forma de acondicionamento das porções de entorpecentes encontradas em poder de Luís Henrique, aliada ao local da abordagem, local conhecido como ponto de venda de drogas, comprovam que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio ilícito. Ao revés, os depoimentos constantes dos autos, seguros e harmônicos, aliados ao auto de exibição e apreensão e ao laudo de exame pericial, comprovam os fatos assim como narrados na denúncia, bem como a autoria e materialidade delitiva. Sendo assim, a procedência da presente ação penal é medida que se impõe. O réu Luís Henrique possui antecedentes criminais e condenação criminal, com trânsito em julgado, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o que demonstra sua personalidade e que faz do comércio ilícito o seu meio de vida e enseja a fixação da pena base acima do mínimo legal, em consonância com o disposto no artigo 59 do Código Penal. O réu é reincidente, o que enseja a majoração da pena e fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda penal. Ante o exposto, requer o Ministério Público seja a presente ação penal julgada procedente, condenando-se os acusados nos termos da denúncia e ora expostos.". Dada a palavra ao Dr. Defensor para alegações finais orais, assim se manifestou: "LUIZ HENRIQUE DIAS TEIXEIRA, vem processado pela suposta violação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 17 de agosto de 2017, na Rua Ernesto Trevisan, nº 165, Jardim Dona Rosina, neste município de Rio das Pedra, o Acusado supostamente trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 28 (vinte e oito) invólucros de plástico contendo cocaína, com peso líquido de 2,02g; e 8 (oito) invólucros de plástico contendo maconha (Cannabis sativa L), com peso líquido de 4,5g. Foi apresentada defesa preliminar, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei 11.343/06. A Denúncia foi recebida em 16 de março de 2022. Superada a fase instrutória, o Parquet sustentou, em sede de memoriais, a procedência dos pedidos formulados na inicial acusatória. No entanto, não merece guarida a pretensão punitiva Estatal. DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA Da acurada análise do conjunto fático-probatório, produzido em Juízo, único capaz de sustentar um decreto penal condenatório (CF, art. 5, LIV e LV, c/c CPP, art. 155), verifica-se que a autoria delitiva não restou adequadamente provada pelos elementos coligidos na fase judicial, conforme será abaixo demonstrado: Do posicionamento do STF sobre o ônus da prova quanto à destinação da droga No atual ordenamento jurídico o réu não tem o dever de demonstrar que a droga encontrada consigo seria utilizada apenas para consumo próprio. Cabe à acusação comprovar os elementos do tipo penal, ou seja, que a droga apreendida era destinada ao tráfico. Ao Estado-acusador incumbe demonstrar a configuração do tráfico, que não ocorre pelo simples fato da compra e da posse de entorpecente. Em suma, se a pessoa é encontrada com drogas, cabe ao Ministério Público comprovar que o entorpecente era destinado ao tráfico. Não fazendo esta prova, prevalece a versão defensiva. Este é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que assim se manifestou no recente aresto abaixo colacionado: (...) "PROCESSO-CRIME. PROVA. Cabe ao Ministério Público comprovar a imputação, contrariando o princípio da não culpabilidade a inversão a ponto de concluir-se pelo tráfico de entorpecentes em razão de o acusado não haver feito

prova da versão segundo a qual a substância se destinava ao uso próprio e de grupo de amigos que se cotizaram para a aquisição". STF. 1ª Turma. HC 107448/MG, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, 18.6.2013. DA IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NO DEPOIMENTO DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PRISÃO A prova dos autos restringe-se à atuação de agentes da segurança pública que atuaram na fase pré-processual. Ocorre que a prova testemunhal encontra-se isolada no contexto probatório. Isto porque a palavra de cada testemunha de acusação deve estar em consonância com as demais provas produzidas no processo, o que não ocorreu no presente caso, em que apenas ficou provada a materialidade do delito, com a efetiva apreensão de drogas, não tendo porém sido provada a autoria delitiva. A dúvida milita a favor do acusado (*in dubio pro reo*). Como é sabido, somente a apreensão da droga é insuficiente para apontar o espoco da mercancia, ainda mais quando desacompanhada dos seguintes elementos de provas: (i) testemunha civil imputado a prática delituosa; (ii) denúncia, ainda que apócrifa, constante dos registros policiais com a atribuição da pecha de traficante; (iii) comprovação de efetivos trabalhos investigativos realizados para a realização da prisão; (iv) comprovação não testemunhal de qualquer ato de venda de entorpecentes. Vale notar que a condenação se fundamenta no depoimento feito justamente pelos responsáveis pela abordagem do Acusado, o que, evidentemente, não pode ser suficiente para um decreto condenatório. E não se trata aqui de tentar revestir de falsidade o depoimento. Mas é inegável que a credibilidade de suas palavras remanesce estremecida tendo em vista o interesse na legitimação de suas atividades. Tais circunstâncias fazem com que seu depoimento, quando isolado, não possa alicerçar uma condenação. Os agentes públicos disseram que foram acionados pelo COPOM para averiguarem um bar que havia um indivíduo armado. Foram até o local e abordaram dois indivíduos, sendo que um deles portava um simulacro de arma de fogo e que com o outro, foi localizado drogas. Afirmaram que o Acusado disse que as drogas seriam destinadas para venda. O PM Rafael não soube dizer se o Acusado possuía dinheiro e confirmou que na data dos fatos foi acionado para averiguar o porte de uma arma de fogo e não de venda de drogas. O PM Gustavo sustentou a mesma versão. Indagado se o Acusado permaneceu preso depois de levado para delegacia, não soube responder se o réu ficou detido. DO INTERROGATÓRIO EM JUÍZO Anote-se que a prova produzida no interrogatório em Juízo também deve ser considerada, constituindo a versão do ocorrido sob o prisma da defesa, sendo verossímeis as ideias externadas pelo Acusado, que, em síntese, em fase policial contou que: Estava no bar junto com outros colegas quando foi abordado pelos PMs. Confirmou que estava em posse de algumas drogas que seriam para seu consumo pessoal e que adquiriu as drogas em Piracicaba. Com relação a quantidade de drogas, afirmou que comprou tal quantidade para não precisar ficar indo para Piracicaba para comprar mais. Declarou que não possuía nenhum dinheiro consigo. Contou, também, que desconhecia que o Valdo estava de posse de um simulacro de arma de fogo. Em juízo, negou todo o ocorrido, afirmando que foi abordado junto com o outro Acusado, que portava o simulacro de arma, e foram conduzidos para delegacia. Contou que foi liberado no mesmo dia, que não permaneceu um dia se quer preso. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 Como já exposto, não há nenhuma prova nos autos que permita afirmar o exercício de tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, o Acusado em sede policial afirmou ser usuário de drogas. Em situações análogas a dos autos a jurisprudência recomenda a desclassificação: "Prova tão-somente da apreensão do tóxico. Insuficiência para configurar o comércio. Desclassificação para a posse de entorpecente. Recurso parcialmente provido – Não basta a apreensão – seja de que quantidade for – de material entorpecente, para a caracterização do tráfico, sendo necessário um mínimo de outros elementos formadores de convencimento" (TJ/SP – AC – Rel. Renato Nalini – RT 693/338). Portanto, havendo dúvida com relação à destinação dos estupefacientes, à luz do princípio *in dubio pro reo*, deve prevalecer a hipótese mais benéfica à defesa. A propósito: "Quando houver dúvida sobre ser traficante ou usuário, deve prevalecer a conclusão de usuário" (TACrimSP, Ac. 178.691, Rel. Geraldo Gomes). DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CARTORÁRIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES O posicionamento jurisprudencial prevalente moldou-se no sentido de que, para a válida consideração da agravante da

reincidência, faz-se necessário o exame de certidão cartorária específica, única hábil à demonstração da efetiva prática de crime transitado em julgado em data anterior ao cometimento da nova infração penal. Meros documentos demonstradores de andamentos processuais, em fase de cognição ou mesmo de execução, por gerarem dúvidas quanto à definitividade da medida eventualmente imposta, não permitem agravar a pena pela reincidência, incumbindo à Acusação a sua efetiva demonstração. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos: PENAL. HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. POLICIAIS. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. AUSÊNCIA DE CONSIDERAÇÃO DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REINCIDÊNCIA NÃO-COMPROVADA POR CERTIDÃO CARTORÁRIA JUDICIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. As decisões judiciais devem ser cuidadosamente fundamentadas, principalmente na dosimetria da pena, em que se concede ao Juiz um maior arbítrio, de modo que se permita às partes o exame do exercício de tal poder. 2. Reincidência não-comprovada por certidão cartorária judicial não pode ser considerada para fins de fixação da pena. 3. Ordem parcialmente conhecida e nesta extensão concedida para anular parcialmente o acórdão e a decisão de primeiro grau, no que se refere à dosimetria das penas, fixando-se novo regime de cumprimento; e para excluir a agravante da reincidência aplicada a um dos pacientes Processo HC 43930; RJ 2005/0074732-8; Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJMG; Julgamento em 22/04/2008; 6ª Turma; Publicado em 12/05/2008. Na mesma linha de raciocínio: Maus antecedentes e reincidência não-comprovados por certidão cartorária judicial não podem ser considerados para fins de fixação da pena. (STJ - HC: 100848 MS 2008/0042187-0) Em vista do exposto, os documentos exibidos nos autos como "Folha de Antecedentes" devem ser desconsiderados para fins de reconhecimento da reincidência, devendo ser reconhecido a redução da pena (tráfico privilegiado). DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO O Acusado é primário (não consta dos autos até o presente momento certidão cartorária dando conta da reincidência), não se dedica a atividades criminosas, bem como não integra organização criminosa (nenhuma prova foi produzida pelo parquet nesse sentido!), razão pela qual de rigor o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, cujo redutor deverá ser aplicado no máximo legal. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA - CONSIDERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA A quantidade e a qualidade de droga não influenciam no fator de redução da pena por ocasião do reconhecimento do privilégio do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Isto porque é na primeira fase da individualização da pena, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, que tal circunstância será valorada. Desta maneira, é impróprio invocar a quantidade e a qualidade da droga no momento da aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, sob pena de flagrante bis in idem, reconhecido pelos Tribunais Superiores: A 2ª Turma, em julgamento conjunto de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, reafirmou orientação no sentido de que a quantidade de substância ilegal entorpecente apreendida deve ser sopesada na primeira fase de individualização da pena, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, sendo impróprio invocá-la por ocasião da escolha do fator de redução previsto no § 4º do art. 33 da mesma lei, sob pena de bis in idem. Com base nesse entendimento, determinou-se a devolução dos autos para que as instâncias de origem procedam a nova individualização da pena, atentando-se para a adequada motivação do fator reducional oriundo da causa especial de diminuição. HC 108513/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 23.8.2011 (HC-108513) RHC 107857/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 23.8.2011. (RHC-107857) (...) O Plenário do Supremo Tribunal Federal reputou configurado bis in idem na consideração cumulativa da quantidade e da espécie da droga apreendida, como indicativos do maior ou menor envolvimento do agente no mundo das drogas, na exasperação da pena-base e no dimensionamento previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. (...) STF. 1ª Turma. HC 122344, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 02/09/2014. (...) Em recentes decisões proferidas em 19 de dezembro de 2013, nos autos dos HC's n.º 109.193/MG e n.º 112.776/MS, ambos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que a utilização da quantidade e/ou qualidade da droga tanto no estabelecimento da pena-base como na aplicação do redutor descrito do art. 33, §

4º, da Lei n.º 11.343/2006 caracteriza bis in idem, entendimento este que, embora não seja dotado de caráter vinculante, deve também ser adotado por esta Corte, em homenagem aos princípios da isonomia e da individualização da pena. No momento da individualização da pena, deve o magistrado escolher em que fase da dosimetria as circunstâncias referentes à quantidade e à natureza da droga devem ser consideradas, cuidando para que sejam valoradas apenas em uma etapa, a fim de se evitar o odioso bis in idem. (...) STJ. 6ª Turma. HC 294.636/SP, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, julgado em 16/09/2014. CONFISSÃO INFORMAL PERANTE A AUTORIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA A afirmação de que outras provas seriam suficientes para condenar O Acusado, a despeito da confissão espontânea, não autoriza a exclusão da referida atenuante, se esta efetivamente ocorreu e foi utilizada na formação do convencimento do julgador. Isto porque, o Código Penal e o Código de Processo Penal não trazem exceções à aplicação do artigo 65, III, "d", consistentes nos motivos que levaram à confissão, ou tocantes à suficiência de outros elementos probatórios. Neste contexto, a alegação das testemunhas de acusação, no sentido de que o acusado teria confessado informalmente a prática delitiva em sede policial, indubitavelmente permite o reconhecimento da atenuante. Eliminando quaisquer dúvidas que possam existir sobre o tema, o Ministro Sebastião Reis Júnior, nos autos do REsp 1.183.157-SP, julgado pela 6ª Turma do STJ em 16/10/2012, ponderou que: (...) "Tendo o acórdão admitido que houve a confissão espontânea, não é devido incursionar-se por supostos motivos subjetivos que teriam levado o réu a confessar, pois, a par de não se poder ter certeza quanto a esses motivos, eles não estão previstos na norma contida no art. 65, III, d, do CP". DA NECESSÁRIA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO A partir da decisão proferida no HC 111.840/ES, em 27/06/2012, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o art. 2º, §1º, que impunha o regime inicial fechado para os delitos hediondos e equiparado. Ademais, a gravidade em abstrato do delito não justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, conforme já sumulado pelo Supremo Tribunal Federal: Súmula nº. 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Súmula nº 719: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. E ainda, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: Súmula 440: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Logo, no caso concreto, a fundamentação apresentada para a imposição do regime inicial mais gravoso é inconstitucional e afastada pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. A fixação de regime diverso daquele graduado na norma exige que o magistrado aponte fundamentos idôneos e concretamente identificados nos autos para tanto. Considerando essa necessária proporcionalidade e ponderando-a com a culpabilidade concretamente demonstrada, tem-se que não há motivo jurídico válido para aplicação do regime fechado, consonante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores na matéria (vide Súmulas citadas). Portanto, no caso em tela, o modus operandi encontra-se no estalão comum, não havendo nada que justifique o regime inicial fechado. Sendo assim, projetando-se a efetiva fixação de pena em patamar inferior a 8 anos de reclusão e considerando a favorabilidade das circunstâncias judiciais, deverá ser fixado o regime aberto de cumprimento de pena ou no máximo o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b e c, e §3º, do Código Penal, pois, no caso, é o que se mostra o mais adequado para a prevenção e repressão do delito. A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS É cabível a substituição de prisão por restritiva de direitos. A baliza jurídica a ser adotada pela sentença penal quando da aplicação do art. 59 do CP admite tal substituição. Ressalte-se que, de acordo com novo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (HC 97.256), é inconstitucional a vedação abstrata da substituição da pena privativa de liberdade nos crimes de tráfico de drogas, tendo a tese sido corroborada pela Resolução 5, de 2012, do Senado Federal, suspendendo a eficácia da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos". Corroborando o entendimento, ambas as turmas do STF, em abril de 2016, sedimentaram o cabimento da fixação do regime aberto e da

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, senão vejamos: PRIMEIRA TURMA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES: FIXAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. Não se tratando de réu reincidente, ficando a pena no patamar de quatro anos e sendo as circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o regime aberto e apreciar a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Com esse entendimento, a Primeira Turma, por maioria, concedeu "habeas corpus" de ofício para garantir ao paciente, condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão pela prática do delito de tráfico de drogas, a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da reprimenda por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução criminal. O Colegiado ressaltou não haver circunstâncias aptas a exasperar a pena. Vencidos os Ministros Rosa Weber (relatora) e Marco Aurélio. Ambos concediam a ordem de ofício, mas para efeitos distintos. A relatora, para determinar que o magistrado de 1º grau procedesse a nova avaliação quanto ao regime inicial de cumprimento da pena e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Ministro Marco Aurélio, para fixar o cumprimento da pena em regime aberto e reconhecer o direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. HC 130411/SP, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, 12.4.2016. (HC-130411) SEGUNDA TURMA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES: FIXAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. Não sendo o paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59), a gravidade em abstrato do crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, não constitui motivação idônea para justificar a fixação do regime mais gravoso. Com esse entendimento, a Segunda Turma, após superar o óbice do Enunciado 691 da Súmula do STF, concedeu "habeas corpus" de ofício para garantir ao paciente, condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão pela prática do delito de tráfico de drogas, a substituição da reprimenda por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais, bem assim a fixação do regime inicial aberto. O Colegiado entendeu que o paciente atende aos requisitos do art. 44 do CP, razão pela qual o juízo deve considerá-los ao estabelecer a reprimenda, de acordo com o princípio constitucional da individualização da pena. HC 133028/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 12.4.2016. (HC-133028) DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE No caso dos autos não há situação que demonstre a necessidade da prisão do Acusado, o que demonstra que a cognição cautelar referente ao periculum libertatis não encontra fundamento de validade no princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) na concreta situação dos autos. Daí a afirmação de que não estão presentes, no caso, os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Por esse motivo, é imperiosa a concessão do direito de recorrer em liberdade ao Acusado (CADH, art. 8.2 c/c CPP, art. 312). DOS PEDIDOS Diante de todo o exposto, requer-se: a absolvição da imputação descrita na denúncia, pela insuficiência de provas quanto à autoria e/ou tipicidade subjetiva do crime; o acolhimento dos pedidos subsidiários, constantes do item anterior, dentre eles o direito de recorrer em liberdade; a desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06; o reconhecimento do tráfico privilegiado com a aplicação do redutor máximo previsto no § 4º, do artigo 33, do Código Penal; o reconhecimento da atenuante da confissão informal; a fixação do regime aberto de cumprimento de pena; a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a imediata emissão de guia de execução provisória, na remota hipótese de condenação sem o deferimento do direito ao recurso em liberdade." Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte sentença: "1. DO RELATÓRIO Trata-se de ação penal de iniciativa pública incondicionada movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de LUIZ HENRIQUE DIAS TEIXEIRA e VANDO DONIZETE RAMOS SANTOS, já qualificado nos autos, imputando ao primeiro a prática do crime do art. 33 da Lei de Drogas e ao segundo o delito do art. 180 do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 17 de agosto de 2017, em hora e local incertos, neste município de Rio das Pedras/SP, o denunciado VANDO adquiriu, em proveito próprio, uma pistola de ar comprimido, sabendo se tratar de produto de crime anterior. Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e espaço acima descritas, o denunciado LUIZ HENRIQUE trazia consigo 28 (vinte e oito) pedras de crack e 08

(oito) porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinando-se as substâncias ao comércio ilícito. Em relação a VANDO, a denúncia foi recebida em 23 de janeiro de 2019 (fls. 104). Por estar em local incerto e não sabido, o réu foi citado por edital (fls. 160/163), suspendendo-se o processo e o curso do prazo prescricional (fls. 181). No tocante a LUIZ HENRIQUE, ele foi notificado às fls. 187. Apresentou defesa prévia às fls. 202/206. A denúncia foi recebida em 16 de março de 2022 (fls. 214). Citado o réu (fls. 235), seguiu-se, então, audiência de instrução, debates e julgamento, realizada nesta data. Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência da pretensão acusatória, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pediu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a infração do art. 28 da Lei de Drogas e, para a hipótese de condenação, pediu a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. É o relatório. 2. DA FUNDAMENTAÇÃO A materialidade está demonstrada às fls. 08/09 e 61/63. A autoria, por sua vez, é certa. O PM Rafael Rodrigues Oliveira afirmou que: não se recorda espontaneamente dos fatos; após a Promotora ler o depoimento prestado pelo declarante na fase extrajudicial, informou que recebeu notícia de rádio dando conta de que havia uma pessoa armada no bar; no local, abordou os réus; LUIZ HENRIQUE trazia drogas consigo e admitiu a prática do tráfico; as drogas estavam em condições de venda; não se recorda se o réu trazia dinheiro consigo; havia denúncias recorrentes de tráfico no bar, mas no dia dos fatos houve apenas denúncia de porte de arma. De seu turno, o PM Gustavo Cesar Cinque Soares prestou declarações em idêntico sentido ao colega de farda. Finalmente, o imputado esclareceu que: a acusação não é verdadeira; não tinha drogas consigo no dia dos fatos; não confirma o depoimento policial de fls. 70/71. Pois bem. Embora o réu negue a propriedade das drogas, há prova bastante em sentido contrário. Consoante declarado pelos militares, as substâncias foram apreendidas na posse dele, o que, outrora, também foi admitido pelo acusado (fls. 70/71). O dolo de tráfico, de seu turno, está bem provado. A quantidade e variedade das substâncias, por si sós, seriam suficientes para comprovar que elas se destinavam ao comércio irregular. Ora, não é crível que o réu tenha saído de casa com 28 (vinte e oito) pedras de crack e 08 (oito) porções para consumi-las em um bar em momento de lazer. Mas não é só. O local dos fatos, como informado pelos militares, era conhecido da PM como ponto de venda de drogas. Os antecedentes criminais do réu também não lhe beneficiam e comprovam o envolvimento dele com o comércio espúrio. Analisando as certidões de fls. 207/2013 e 238/241, nota-se que, tanto antes quanto depois dos fatos descritos na denúncia, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, por sentença já transitada em julgado. Com efeito, na ação penal nº 001165-87.2012.8.26.0511 ele foi condenado pelo crime de tráfico de drogas praticado em 12.06.12 e na ação penal nº 1501513-70.2019.8.26.0548 pelo mesmo delito praticado em 17.05.19. Sendo o réu reincidente, há obstáculo legal à aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 3. DO DISPOSITIVO Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei de Drogas c.c. art. 61, I, do Código Penal. Passo, doravante, a dosar a pena. Na primeira fase, nada a considerar. Na segunda fase está presente a reincidência, que, por ser de natureza específica, implicará a majoração da pena em 1/5 (um quinto). Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição, pelo que estabeleço a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. No tocante ao regime inicial, declaro, de modo incidental, a inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, por ofensa ao princípio da individualização da pena (cf. STF, HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli). A estipulação do regime inicial será feita, portanto, com fundamento no art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal. Considerando a reincidência específica, fixo o regime inicial fechado. À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 avós do salário mínimo. Em razão a quantidade de pena imposta, incabível sua substituição, nos termos do art. 44 do Código Penal. 4. DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS Defiro recurso em liberdade. Condeno o réu no pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, observada

a gratuidade processual, ora deferida. Autorizo a destruição dos entorpecentes. Comunique-se. Providencie a z. Serventia o desmembramento dos autos em relação ao réu VANDO DONIZETE RAMOS SANTOS. Transitada em julgado a sentença: a) inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se o IIRGD para fins de registro; c) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; d) expeça-se guia de execução definitiva. Publicada em audiência, saem os presentes intimados." Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, com a concordância das partes. Eu, ANA LUISA LORANDI FALDA, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MINISTÉRIO PÚBLICO:

Deseja recorrer desta sentença: sim () não (X).

ADVOGADO:

Deseja recorrer desta sentença: sim (X) não ().

RÉU:

Deseja recorrer desta sentença: sim (X) não ().

Após, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Recebo o recurso interposto pelo réu. O ilustre advogado já sai intimado para apresentação das razões recursais no prazo legal."